

1500701-37.2021.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... casa. Quanto aos fatos, negou o tráfico de drogas. Narrou que as drogas eram destinadas ao seu consumo pessoal. Na Delegacia, foi forçado a confessar a prática do tráfico de drogas. Negou que houvesse balança de precisão no imóvel ou caderneta com anotações do tráfico de drogas, salientando que os policiais forjaram essas provas para incriminá-lo. Assumiu a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500701-37.2021.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500701-37.2021.8.26.0587 - Controle nº 2021/001412

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALERSON MARCEL PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 200/203, RICKELMY PEREIRA PINTO, qualificado as fls. 05/06 e ALERSON MARCEL PEREIRA, vulgo "Pitoco", qualificado as fls. 08/09, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 12h30min, na Rua Paquetá, nº 51, bairro Maresias, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, previamente ajustados entre si, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo e mantinham em depósito para fins de tráfico, 02 (dois) papелotes com cocaína, pesando aproximadamente 5,35g (cinco gramas e trinta e cinco centigramas), drogas que causam dependência química e psíquica, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno na cor azul, contendo anotações típicas do tráfico, 02 (dois) aparelhos de telefonia celular, das marcas Motorola e LG e a importância de R\$ 1090,00 (mil e noventa reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, auto de constatação preliminar de fls. 23 e laudo toxicológico definitivo de fls. 296/298. Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, na Rua Paquetá, nº 51, bairro Maresias, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, RICKELMY PEREIRA PINTO, qualificado as fls. 05/06, possuía 01(um) revólver da marca

Taurus, calibre .380, de uso permitido, municiada com 23 (vinte e três) cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e Laudo pericial da arma de fogo aprendida de fls. 255/257 e 299/301.

Em razão destes fatos, os réus RICKELMY PEREIRA PINTO e ALERSON MARCEL PEREIRA foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c artigo 29, "caput", do Código Penal; e RICKELMY PEREIRA PINTO, como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em audiência de instrução e julgamento, pelo Ministério Público foi requerido o aditamento à denúncia em face da juntada do laudo pericial de fls. 299/301, nos seguintes termos: "MM. Juiz: Nos termos do art. 384 do CPP adito a Denúncia a fim de fazer constar da mesma a descrição de novo elemento fático relevante para o deslinde do feito, qual seja, aqueles constantes do laudo pericial que veio aos autos a fl. 299/301 em 06/12/2021. Adito a denúncia para fazer constar que a arma de fogo possuída pelo acusado RICKELMY se trata de arma de fogo com número de série suprimido, razão pela qual o fato subsume-se ao art. 16, IV da Lei 10826/03. Assim, adito a denúncia requerendo que tal aditamento seja reduzido a termo, constando em ata, oportunizando as Defesas que se manifestem sobre o mesmo". Pela Defensoria Pública e pela defesa constituída foi dito que não se opunham ao aditamento ministerial, bem como que não tinham quaisquer requerimentos adicionais (fls. 321/322).

Recebida a denúncia às fls. 227/228, bem como seu aditamento de fls. 321/322, devidamente citados (fls. 242 e 243) os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 247/249). Mantido o recebimento da denúncia (fls. 263/268), em instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo os réus ao final interrogados (fls. 321/322).

Em memoriais de alegação finais (fls. 337/347), o Ministério Público, ao final da instrução probatória, requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, aduzindo que restaram provados os fatos narrados na peça acusatória.

A Defesa de Alerson, em memoriais de alegação finais (fls. 369/385), sustentando insuficiência de provas, requereu a improcedência da pretensão punitiva estatal, em conformidade com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação do delito previsto no art. 33, caput, para o crime previsto no art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006. Requereu a aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33 da Lei de Drogas). Quanto ao regime, pugnou pela fixação do aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a isenção da pena de multa, o direito da acusada de recorrer em liberdade e, enfim, aplicado o instituto da detração penal.

No mesmo sentido, a Defesa de Rickelmy, em memoriais de alegação finais (fls. 369/414), sustentando insuficiência de provas, requereu a improcedência da pretensão punitiva estatal, em conformidade com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação do delito previsto no art. 33, caput, para o crime previsto no art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, também, requereu a aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33 da Lei de Drogas). Quanto ao delito descrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, pugnou pela absorção da conduta tipificada no Estatuto do Desarmamento pela causa de aumento prevista da Lei de Drogas (art. 40, inciso IV), realizando a reclassificação da conduta. Requereu que a pena base seja fixada no mínimo legal, para ambos os crimes. Requereu a aplicação da atenuante da menoridade relativa para ambos os crimes. Pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea na realização da dosimetria do crime de posse de arma de uso restrito, caso não seja acolhido o pedido de absorção da conduta tipificada no Estatuto do Desarmamento, acima mencionada. Subsidiariamente, o reconhecimento e aplicação da atenuante diferida da menoridade relativa e sua consequente compensação com a causa de aumento do emprego de arma de fogo no tráfico de drogas. Quanto ao regime, pugnou pela fixação do regime, conforme a pena aplicada, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a isenção da pena de multa, o direito da acusada de recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/15), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17); Laudo pericial da arma de fogo apreendida (fls. 255/157 e 299/301), Laudo de Constatação (fls. 293/295), Laudo químico toxicológico (fls. 296/298) e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla

Defesa.

Quanto ao acusado RICKELMY, a autoria é igualmente certa e repousa sobre o réu. Por outro lado, quanto ao corréu ALERSON pairam dúvidas quanto à autoria. Vejamos:

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial civil Francelso Ricardo Siqueira narrou que estavam pelo bairro de Maresias cumprindo ordens de serviço, entregando intimações, porém, já tinha informação de que a pessoa de Rickelmy era autor de um roubo a uma lotérica do bairro Maresias, sendo certo que ao ser identificado ele se evadiu da cidade. Diante da notícia de que ele - Rickelmy - havia retornado, resolveram diligenciar até a residência dele, mas tomaram conhecimento de que ele havia se mudado e, por isso, diligenciaram pelo bairro até localizarem o novo endereço. Rumaram para o local e foram atendidos pelo réu. Ao ser questionado acerca do roubo, Rickelmy confessou. Em revista pessoal, localizaram dois papелotes de cocaína, ao ser questionado se na residência havia mais drogas, o réu respondeu negativamente, porém, admitiu que possuía uma arma de fogo escondida no local. Franqueada a entrada na residência, localizaram a arma de fogo dentro da caixa acoplada de uma privada. Acresceu que a pessoa Alerson, de vulgo "Pitoco", que seria padrasto do réu Rickelmy e conhecido dos meios policiais por tráfico de drogas, estaria no interior da residência. Diante disso, deram voz de prisão aos dois. Em busca pela casa lograram localizar as munições da arma.

Acresceu que quando se aproximaram da residência, acredita que foram visualizados por "Pitoco", que possivelmente se livrou de algumas drogas e escondido a arma na caixa acoplada do vaso sanitário. Asseverou que Rickelmy assumiu ter sido autor do crime de roubo à Lotérica, bem como a traficância, dizendo que as drogas localizadas foram adquiridas no bairro Topolândia, seriam fracionadas e revendidas pelo bairro de Maresias. Nesse contexto, uma balança de precisão - que era utilizada para fracionar as drogas - também foi localizada. Ao Ministério Público respondeu: O policial Rodrigo presenciou os mesmos fatos, descritos acima.

Ressaltou que receberam informações da população no sentido de que os réus estavam traficando drogas pelo bairro de Maresias. Asseverou que não localizaram mais drogas no local, mas encontraram um caderno com anotações e a pessoa de Rickelmy admitiu que as drogas já tinham todas sido vendidas. Declarou que o réu possuía dois celulares e fazia serviço de entrega de drogas via "delivery". Acresceu que o caderno de anotações, a balança de precisão, a arma de fogo e as munições foram localizados no quarto do imóvel que pertencia a Alerson, embora Rickelmy tenha admitido sua propriedade. À Defesa de Alerson respondeu: Na data dos fatos, localizaram - durante a revista pessoal em Rickelmy - duas porções de entorpecentes, tendo ele admitido que estava traficando. À Defesa de Rickelmy respondeu: Durante a revista pessoal em Rickelmy localizaram duas porções de entorpecentes, sendo que ele confessou estar traficando; não se recorda a quantia em dinheiro que foi apreendida; os denunciante não querem se comprometer.

No mesmo sentido foram os relatos do policial civil Rodrigo do Valle Chemzarian, em nada divergindo o depoimento de ambos. Acresceu que localizaram duas porções de cocaína no bolso de Rickelmy. O acusado Alerson, vulgo "Pitoco" - padrasto de Rickelmy -, também estava no local. Além das drogas, localizaram uma arma de fogo, no interior de uma caixa acoplada, além de caderneta e balança de precisão. À Defesa de Alerson respondeu: Na data dos fatos, localizaram - durante a revista pessoal em Rickelmy - duas porções de entorpecentes, tendo ele admitido que estava traficando; não presenciou conduta típica de traficância; asseverou que Rickelmy confessou que realizava o tráfico de drogas, via "delivery", inclusive apreenderam o aparelho celular que ele utilizava para realizar as entregas das drogas.

O acusado Alerson Marcel Pereira negou a prática delitiva. Narrou que, na data dos fatos, visualizou os policiais pelo bairro. Não presenciou se os policiais localizaram drogas na residência ou arma de fogo. Estava na cozinha no momento da chegada dos policiais. Chamaram Rickelmy e disseram ter localizado duas porções de cocaína com ele. Admitiu já possuir condenação por roubo. Declarou desconhecer a balança de precisão localizada no interior do imóvel. Disse que no imóvel havia a importância de R\$ 1.100,00 proveniente do seu trabalho e seria destinado ao pagamento do aluguel. Não tinha conhecimento de que Rickelmy praticava conduta ilícita. À época dos fatos, trabalhava como pintor.

O acusado Rickelmy Pereira Pinto disse que possui três passagens na fundação casa. Quanto aos fatos, negou o tráfico de drogas. Narrou que as drogas eram destinadas ao seu consumo pessoal. Na Delegacia, foi forçado a confessar a prática do tráfico de drogas. Negou que houvesse balança de precisão no imóvel ou caderneta com anotações do tráfico de drogas, salientando que os policiais forjaram essas provas para incriminá-lo. Assumiu a propriedade da arma apreendida. Nega que estava traficando, tendo apenas confessado, pois sofreu ameaças.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado Rickelmy, diante das provas produzidas.

O réu Rickelmy, em juízo, afirmou que sofreu ameaças por parte dos policiais para confessar a traficância. Perante a autoridade policial se calou acerca das supostas ameaças. Tampouco, utilizou dos meios disponíveis para denunciar os policiais de forma anônima. Além disso, o réu também poderia ter registrado um boletim de ocorrência delatando abuso de autoridade e ameaças, supostamente cometidos pelos mesmos policiais, mas não o fez.

A doutrina majoritária entende que:

"Cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas. A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, artigo 156, caput). Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais". GN

Ademais, o acusado também não comprovou atividade lícita, apesar de afirmar que não estava mais traficando. Nada produziu a arrostar os relatos policiais. Nenhuma testemunha sequer, ainda que abonatória infirmou os depoimentos firmes prestados em sede policial e em juízo, uníssonos no sentido de que ele confessou voluntariamente, em solo policial e informalmente, a prática do tráfico de drogas. Por outra lado, os policiais narraram os fatos em conformidade com as provas dos autos. O policial civil Francelso, em juízo, em síntese, disse que, na data do fatos, foi até a residência do acusado Rickelmy em razão de outro fato típico. No local foram atendidos por ele e ao ser questionado acerca do roubo, Rickelmy confessou. Em revista pessoal, localizaram dois papелotes de cocaína. Rickelmy admitiu que possuía uma arma de fogo escondida no local. Em buscas pela casa lograram localizar a arma e as munições. Rickelmy assumiu estar traficando e que as drogas localizadas foram adquiridas no bairro Topolândia, foram fracionadas e revendidas pelo bairro de Maresias. Uma balança de precisão e um caderno com anotações do tráfico foram localizados. Rickelmy admitiu que as drogas já tinham todas sido vendidas. O réu possuía dois celulares e fazia serviço de entrega de drogas via "delivery". O policial civil Rodrigo do Valle Chemzarian confirmou os fatos narrados por seu colega de farda, em nada divergindo o depoimento de ambos. Ressalta-se a palavra das testemunhas policiais, que de maneira segura, uniforme e convergente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem do acusado e a apreensão da droga.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade do testemunho policial.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias em que se deu a prisão são fatores que, associados à prova produzida, levam à certeza de que o réu efetivamente se dedicava à mercancia de entorpecentes - PENA - MULTA - QUANTUM - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - A quantidade da pena de multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade - Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes - Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso concreto - Condenação mantida - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO" (TJSPAp.n. 0084921-43.2010.8.26.0000 - 15ª Cam. Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA j. 16.12.2010) - gn.

Ademais, as circunstâncias da prisão em flagrante, os objetos relacionados ao tráfico (balança de precisão, caderno de anotação do tráfico de drogas), a confissão informal do acusado RICKELMY, bem como sua confissão perante a autoridade policial (fls. 05/06), evidenciam que referidas drogas eram destinadas ao comércio ilícito de entorpecentes. Por tais razões, também, incabível a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal.

Quanto ao pleito defensivo, não há que falar em absorção da conduta tipificada no Estatuto do Desarmamento pela causa de aumento prevista da Lei de Drogas (art. 40, inciso IV). No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico (HC n. 181.400/RJ, Quinta Turma, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/6/2012), o que não se verificou no presente caso. Saliente-se que Rickelmy, em solo policial, relatou ter adquirido a arma para se defender, eis que estava ameaçado em Maresias (fls. 05/06). Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". gn

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Em arremate, a intenção mercantilista do acusado deriva das quantidades, ainda que

em pequena quantidade, apreendidas em seu poder, bem como das demais circunstâncias em que tais drogas e o dinheiro foram apreendidos. De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310).

Igualmente quanto ao crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, uma vez que os relatos dos agentes da lei foram firmes ao revelar que durante buscas, acima relatadas, além da confissão judicial do réu Rickelmy, no interior da residência do acusado, também foram localizados uma arma de fogo com a numeração suprimida e munições para tal arma.

Ademais, o exame pericial confirmou que as munições e arma de fogo de mesmo calibre estavam aptas ao disparo, além de que a numeração de série havia sido suprimida mediante raspagem (fls. 255/257 e fls. 299/30).

Provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, bem como do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, a condenação do réu RICKELMY é medida que se impõe.

Por outro lado, quanto ao corréu ALERSON, na análise das provas coligidas, em que pese restar comprovada a materialidade delitiva, verifica-se que o conjunto probatório é frágil para acarretar a condenação criminal dele.

Sem dúvida que a condenação do acusado ALERSON, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida e isso porque, após atento exame das provas colhidas, não se tem certeza de pertencer ao acusado os itens localizado em seu dormitório, descritos na denúncia, muito menos de que o acusado estaria traficando no local dos fatos. Os policiais foram taxativos ao afirmar à Defesa dele que Alerson negou a traficância, bem como alegou desconhecer o envolvimento de Rickelmy com o comércio espúrio. O que foi mantido por ele em ambas as fases. Em juízo, nenhum elemento de prova foi produzido para embasar o decreto condenatório.

Com efeito, é entendimento pacífico em nossa jurisprudência de que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei e, de outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento, por outro lado, no caso dos autos, os relatos policiais não comprovam cabalmente que Alerson esteja envolvido na traficância. Assim, ausente comprovação da autoria do delito em tela, a dúvida deve ser resolvida em favor do réu Alerson.

Em tal contexto, resta evidente não surgir a prova dos autos como límpida e firme para fins de condenação do acusado Alerson, surgindo a decisão absolutória como a mais acertada, pois em tal sentido a jurisprudência dominante ensina que “para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação” (TACRIM - AC - Rel. JuizCamargo Sampaio - RT 549/348).

Resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção.

Quanto ao delito de Tráfico de Drogas.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo em fls. 205 e fls. 148/149 que o réu Rickelmy não possui Maus antecedentes. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Entendo não ser o caso de aumento da pena em razão da quantidade e variedade de entorpecente apreendido, na medida em que a situação do caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de tráfico de entorpecentes.

Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu é primário e tem a seu favor a atenuante da menoridade relativa. Mas a pena já está no mínimo e não pode ficar

aquém do mínimo legal, nesta fase (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, verifico estar presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, levando-se em conta a primariedade do acusado e a ausência de indícios concretos de que se dedicasse às atividades criminosas antes do dia dos fatos ou que integrasse organização criminosa. Dessa forma, diminuo a pena na fração de 2/3, considerando, também, a quantidade inexpressiva de entorpecente apreendidos, resultando assim uma pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ressalto que, embora tenha passagens pelo Juizado da Infância e Juventude, isso não é o bastante para afastar a redução de pena aqui mencionada. Nesse sentido, há jurisprudência, inclusive do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, § 4º, da Lei 13.343/06. Sentença condenatória. Irresignação do Ministério Público quanto à aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, e quanto ao regime inicial. 1. Tráfico privilegiado. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado, já que o réu é primário, não se dedica à atividade criminosa e não integra qualquer organização ou associação para o tráfico. Atos infracionais que não caracterizam reincidência e não podem ser valorados negativamente a título de antecedentes. Precedentes do STF e do STJ. Quantidade da droga apreendida, ademais, que não é alta a justificar a diminuição do quantum de redução da pena. 2. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direito. Possibilidade. Requisitos legais preenchidos. Ausência de hediondez no tráfico privilegiado, que, de qualquer forma, não impediria a fixação do regime aberto e nem a substituição por penas alternativas. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 15048245820198260196 SP 1504824-58.2019.8.26.0196, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 28/05/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021)

Quanto ao delito de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Na primeira fase, conforme acima mencionado, o réu não possui maus antecedentes, por isso fixo a pena no mínimo legal em 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu é primário e tem a seu favor a atenuante da confissão e a menoridade relativa. Mas a pena já está no mínimo e não pode ficar aquém do mínimo legal, nesta fase (Súmula 231 do STJ).c

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, as penas permanecem inalteradas.

As penas dos crimes de Tráfico de Drogas e de Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deverão ser somadas para fins de cumprimento, haja vista a ocorrência de CONCURSO MATERIAL, nos termos do artigo 69 do Código Penal, uma vez que os crimes foram praticados mediante condutas distintas e autônomas, razão pela qual torno a pena total e definitiva do acusado em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

O artigo 33, § 2º, b, do CP estabelece que o condenado à sanção superior a 4 e não excedente a 8 anos poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, observando-se os critérios do art. 59 do aludido diploma legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que fixada a pena-base no mínimo legal e sendo o acusado primário e detentor de bons antecedentes, não se justifica a fixação do sistema carcerário mais gravoso (Súmula n. 440 do STJ). Desse modo, a teor do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao acusado.

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, considerando a quantidade de pena aplicada (Art. 44, I, CP). Pelo mesmo motivo, sobretudo pela quantidade de pena aplicada, não há que

se falar em suspensão condicional da pena (Art. 77, CP).

Inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, bem como considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, não há detração a ser procedida no momento, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei 12.736/2012. Para tanto, remeto à VEC a aplicação do art. 387, §2º, CPP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência:

CONDENO o acusado RICKELMY PEREIRA PINTO, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no regime prisional inicial semiaberto, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10826/2003, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

ABSOLVO o réu ALERSON MARCEL PEREIRA, qualificado nos autos, dos fatos a ele imputados na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado Alerson Marcel Pereira. Quanto ao acusado Rickelmy Pereira Pinto, diante do regime aplicado, semiaberto, desproporcional a manutenção do acusado em restrição de liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Nesse sentido: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário' (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). Voto da ministra Cármen Lúcia concedeu a ordem por considerar evidente o constrangimento ilegal, expondo que "Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. (STF, HC 182.567/RJ, j. 18/03/2020)., Os réus não apresentaram prova da origem lícita do dinheiro com eles apreendidos, razão pela qual decreto a sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário. No que tange a arma e munições, diante da prolação de sentença e considerando que a arma de fogo e o projétil apreendidos não mais interessam à persecução penal, decreto a perda da arma de fogo e do projétil e determino a sua destruição. Comunique-se a Secretaria de Estado da Segurança Pública, que deverá providenciar a destruição da arma de fogo e do projétil, devendo comunicar a efetiva destruição, nos termos do disposto no artigo 511 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Oficie-se, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10.826/03.

Quanto aos demais objetos apreendidos, descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, comunique-se a Autoridade Policial para que determine sua destinação, na forma do artigo 516 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça: "Art. 516. Findo o processo, o inquérito policial, o termo circunstanciado ou o procedimento de apuração de ato infracional, não havendo deliberação judicial noutro sentido, será comunicada à Autoridade Policial para que dê destinação aos objetos, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP".

Oficie-se à delegacia, autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Condene o corréu Rickelmy a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13,



da Lei 1.060/50.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal dos réus, expeça-se o necessário quanto ao dinheiro, bens, armas, munições e às drogas.

Cumpra-se.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA